

1501080-83.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157915/2020 - 80º D.P. VILA

JOANIZA, 12148348 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 1198/20/344 - 80º D.P. VILA JOANIZA,

2157915 - 80º D.P. VILA JOANIZA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501080-83.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501080-83.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157915/2020 - 80º D.P. VILA

JOANIZA, 12148348 - 80º D.P. VILA JOANIZA, 1198/20/344 - 80º D.P. VILA JOANIZA,

2157915 - 80º D.P. VILA JOANIZA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELA DOS SANTOS ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHAO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra MARCELA DOS SANTOS ANDRADE (fls. 99/100), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2020, às 12 horas, na Rua Guilherme Gonçalves do Rosário, n.º14, Viela Rouxinol -

Pirajussara, nesta Cidade e Comarca, MARCELA DOS SANTOS ANDRADE, qualificada às fls. 16/17, tinha em depósito, para fins de comercialização a terceiros, 9006,9

gramas de maconha, acondicionadas em 06 tijolos, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação de fls. 13/15 e laudo do exame químico-toxicológico de fls. 91/93.

A denúncia foi recebida em 01.10.2020 (fls. 101/102).

Regularmente notificada, a denunciada apresentou defesa prévia por intermédio de defensor constituído, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 142/143).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 07.06.2021 (fls. 346/347 e 370).

Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e decretou-se a revelia da ré, restando prejudicado o interrogatório, porque mudou de residência sem comunicar o juízo, não tendo comparecido à solenidade. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais oralmente (termo de audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, ingresso diretamente na análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); boletins de ocorrência (fls. 7/9); auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar da substância apreendida (fls. 10 e 13/15); e do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 91/93). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidos com a acusada 9006,9 g de maconha, acondicionados em 6 (seis) tijolos, tendo o exame químico-toxicológico atestado que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria em relação à acusada também é certa, exurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial (fls. 3 e 4), quanto em juízo, os policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante da acusada, Marcos Fernando Pacheco e Marcelo Sales Rezende Vieira, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram narrativas harmônicas, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Relataram, em uníssono, que: no bojo de investigação sobre tráfico de entorpecentes, chegou à unidade policial denúncia de que, na residência situada na Rua Guilherme Gonçalves Rosário, 14, estavam sendo armazenadas drogas destinadas à comercialização; diligenciaram até o local dos fatos, onde foram recebidos pela acusada, a qual lhes franqueou a entrada; na cozinha, dentro de uma caixa de papelão, localizaram e apreenderam seis tijolos de maconha, encapados em fita plástica; informalmente, a implicada admitiu que armazenava a substância entorpecente para um sujeito de nome Thales, mas não esclareceu quanto recebia para tanto.

Silente em solo policial (fl. 5), a ré não foi interrogada em juízo, porquanto revel.

Os seguros, claros e congruentes testemunhos dos policiais civis, que têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - sobretudo em casos como o presente, envolvendo o tráfico de drogas, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar os réus (como na espécie, até porque não os conheciam) -, formam quadro probatório suficiente à formação da autoria delitiva. A par disso, eventual origem lícita e as razões para o armazenamento da droga encontrada em poder da acusada não foram comprovadas nos autos.

Nesse cenário, a defesa não comprovou o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva alegado (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria.

Ressalto, em remate, não ser necessária a constatação da aquisição e/ou venda (distribuição propriamente dita) da droga para que a agente seja responsabilizada criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ela traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao

comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186).

Tampouco comporta acolhida o pleito subsidiário da defesa pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, estampado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Na hipótese, a significativa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (mais de 9 kg) desvela a gravidade em concreto da conduta, a indicar o grau de envolvimento do agente na atividade criminosa, e não um desvio pontual, máxime porque ao pequeno traficante não é confiada expressiva carga de drogas.

Como destacou o eminente Desembargador Camargo Aranha Filho na Apelação Criminal nº 1523060-25.2020.8.26.0228, julgada pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 07.06.2020, em acórdão de sua relatoria, “na interpretação da referida causa de diminuição de pena deve o juiz atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o objetivo legal foi de beneficiar com a sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a reprovação do comportamento. (...) a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas pode vir assentada na prova indiciária, que se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), sob pena de inviabilizar a repressão penal a este tipo de delito, na medida em que os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas' (STF, HC nº 101.519, Relator Ministro Luiz Fux, DJe em 25/4/2012). Acresço que a primariedade e os bons antecedentes não determinam de forma sistemática a incidência da causa de diminuição.”

Em suma: a situação do acusado, surpreendido na posse de quantidade portentosa de maconha, não é própria de quem está se iniciando neste hediondo comércio, de modo que não está preenchido o requisito de não dedicação a atividades criminosas.

Como se não bastasse, a ré ostenta apontamento de ato infracional em 2016 (fl. 30), também a revelar a dedicação a atividades criminosas (nesse sentido: STJ, AgRg no HC 488.570/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.08.2019, DJe 23.08.2019; e STJ, HC 431.001/RS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.03.2018).

Incabível, enfim, a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização da acusada como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de rigor.

Passo a dosar as penas aplicáveis a ela, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no

art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Consoante supra consignado, a quantidade portentosa da droga (maconha), de reconhecido potencial lesivo, enseja, em linha de princípio, maior reprovação penal. Todavia, a fim de não incorrer em bis in idem, valorá-la-ei apenas na terceira etapa da dosimetria para afastar o redutor estatuído no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos HCs n. 109.193/MG e 112.776/MS, firmou a orientação de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da pena, ou na primeira ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa, sob pena de bis in idem.

2. Uma vez que o Juiz sentenciante utilizou o mesmo fundamento (quantidade de drogas apreendidas) para justificar tanto a exasperação da pena-base quanto a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, deve ser determinado o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja procedida à nova dosimetria da pena, dessa vez com a utilização da quantidade de drogas apreendidas em somente uma das etapas da dosimetria.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 358850/SP n. 2016/0151207-0, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 26.09.2018);

[...] Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas.

3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes.

4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena.

5. Reafirmação de jurisprudência. (STF, ARE 666334 RG, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.04.2014, DJe 05.05.2014); e

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÃO. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do 70, do Código Penal, todos enlaçados em concurso material de delitos. Preliminar de nulidade. Ilícitude da prova. Não reconhecimento. Busca e apreensão domiciliar desprovida de mandado judicial. Ingresso dos policiais autorizado pelo réu. Procedimento legítimo diante da prática de crime permanente. Advertência sobre o direito ao silêncio.

Desnecessidade. Mérito. Materialidade e autoria dos delitos não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Condenação acertada. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade de substâncias apreendidas para elevar a pena-base e impedir a aplicação do tráfico privilegiado, configura vedado bis in idem. Basilar devolvida ao piso legal.

Afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido em ocasião de calamidade pública. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Precedentes. Caso concreto que não admite a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Quantidade elevada de drogas que revela a dedicação do sentenciado à atividade criminosa. Bem reconhecido o concurso formal entre os artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03. Orientação mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e acolhida nesta Colenda Câmara. Tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos. Regimes iniciais mantidos. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 1502451-43.2020.8.26.0544, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 31.05.2021). (Negritei). De outra banda, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é inerente à espécie; a ré é primária; o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são

próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes nem agravantes, remanescendo a pena tal qual dosada na etapa anterior.

Na terceira fase, também não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena - conforme motivado acima -, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, em vista do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de pena imposta (arts. 44, I, e 77, caput, ambos do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR a ré MARCELA DOS SANTOS ANDRADE, já qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Considerando que a ré foi colocada em liberdade provisória (fls. 46/48) e apenada com sanção corporal a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), salvo se por outro motivo estiver presa.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso, e não houve pedido expresso da acusação nesse tocante.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração - caso ainda não tenha realizado.

Certificado o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome da ré no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral da acusada para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para fins de registro dos antecedentes criminais da acusada; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, a acusada para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA